

1500686-90.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 6ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/08/2022

... o vício.

E, como já se decidiu:

Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Reconhecimento da inimputabilidade em razão da dependência química - Impossibilidade - Não demonstração nos autos de que o apelante tinha o discernimento comprometido tanto no momento da ação, como em qualquer ato do processo - Condenação mantida - Recurso improvido. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTOS
Foro de Santos
6ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500686-90.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital :
1500686-90.2022.8.26.0536 - Controle n.º 168/22
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réus:
KLEBER SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

KLEBER SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta de 21h31min, na Rua Brás Cubas n.º 227, sala 2, bairro Vila Nova, neste município e comarca, mediante destruição de obstáculo, subtraiu, para si, dois aparelhos celulares, da marca Apple, avaliados em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencentes à Contabilidade Saint Germain. Diz a denúncia que, durante o repouso noturno, o réu caiu de dez metros de altura, arrombou uma porta do escritório de contabilidade situado no local e assim ingressou no estabelecimento. No interior do escritório, danificou diversos objetos, ingeriu bebidas alcoólicas que lá estavam e subtraiu dois aparelhos celulares iPhone, da marca Apple. Acionados, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram ao local. Por fim, afirma a denúncia que a secretária do escritório foi contatada pela Polícia Militar e reconheceu os aparelhos celulares furtados, os quais foram

restituídos, como consta do auto de exibição, apreensão e entrega juntado a p. 4 (pp. 57/58).

Recebida a denúncia (pp. 61/62), foi o réu citado pessoalmente (p. 85). A Defesa ofereceu a resposta de p. 89, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 90/91).

Na instrução, foram ouvidas a representante da vítima e duas testemunhas, procedendo-se ao interrogatório (pp. 129/130).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Em complementação, requereu a majoração da pena-base, diante da presença de maus antecedentes, e o reconhecimento da reincidência em crimes patrimoniais (gravação audiovisual de pp. 129/130 e p. 166).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações orais, pleiteou a absolvição, alegando que o fato não constituiu infração penal, uma vez que o acusado era completamente incapaz de entender a ilicitude de sua conduta. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como da causa de diminuição de pena pela tentativa. Pugnou, ainda, pela exclusão da causa de aumento de pena decorrente do repouso noturno, em vista do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Ademais pleiteou a fixação de regime inicial semiaberto, caso se comprovada a reincidência, ou regime inicial aberto, na hipótese de se constatar sua primariedade, com a respectiva revogação da prisão cautelar e a substituição por penas alternativas (gravação audiovisual - pp. 129/130 e certidão de p. 172).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de exibição, apreensão e entrega (p. 4) e pelo laudo pericial (pp. 116/123).

A autoria também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, o acusado relatou que entrou no estabelecimento porque ouviu pessoas conversando no interior do local e foi até lá para retirá-las, pois o escritório estava fechado. Informou que, de fato, pegou os celulares dessas pessoas, mas quando os bombeiros chegaram, avisou sobre a apropriação. Afirmou que não teve a intenção de furtar nada. Disse que conhece a dona do estabelecimento (p. 10).

Em juízo, ao ser interrogado, o réu informou que seu nome é Kleber Santos Silva, sendo que Cleber de Jesus Santos é o seu registro civil no qual consta apenas a filiação em nome de sua mãe. Informou que foi processado e condenado por sequestro e assalto e em razão dessas condenações sua pena somou 44 anos. Há quatro anos estava cumprindo penal em regime aberto. Disse que os processos são de Santos, Cubatão e Piracicaba. Reside com sua mãe no prédio onde ocorreram os fatos aqui apurados. Conhece a testemunha Jéssica, que é secretária do escritório, e também Ana, a proprietária do estabelecimento. Os policiais conheceu em razão destes fatos. Nada tem contra essas pessoas. Contou que sofre com a dependência química, pois é viciado em drogas e tem alucinações com frequência. No final de semana estava de folga e começou a usar drogas e ingerir bebidas alcoólicas desde o sábado. Disse que ouviu vozes no andar de baixo de sua residência, desceu e começou a gritar em frente à porta do imóvel. Assim, seus familiares perceberam que estava sob efeito de drogas, levaram-no para cima e o trancaram no quarto. Afirmou que, após isso, subiu no telhado, escorregou e caiu no quintal da imobiliária. Seu primo, que é do Corpo de Bombeiros e os visitava no momento, acionou uma equipe para que o retirassem do local em que havia caído. Informou que, sob efeito de alucinações, forçou a porta e entrou na imobiliária na tentativa de encontrar as pessoas cujas vozes ouvia. Arrastou os móveis e armários para tentar encontrá-las, mas não abriu gavetas, nem malas. Disse que pegou os celulares imaginando que fossem das pessoas que ali estavam. Ameaçou entregar os celulares às autoridades caso essas pessoas não aparecessem. Atualmente, tem ciência que se tratava de uma alucinação. Narrou que ao ser resgatado pelos bombeiros, perguntaram de quem eram os aparelhos celulares, ao que ele respondeu que eram das pessoas que estavam

dentro do escritório. Disse a eles que estava sob efeito de cocaína. Então, entregou os três telefones ao bombeiro, referindo-se aos dois que pegou no escritório e o seu próprio celular. Após o resgate, a Polícia Militar já estava no local e o bombeiro entregou os telefones celulares aos policiais. Foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, foi conduzido à delegacia. Por ainda estar sob efeito de drogas, não prestou declarações. O seu celular também foi entregue para Jéssica que o entregou para sua mãe. Alegou que não tinha a intenção de subtrair os aparelhos celulares e que os encontrou em cima de uma mesa. Contou, ainda, que, certa vez, chegou sob efeito de drogas e sua mãe não quis abrir a porta de casa para ele. Então, arrombou a porta do prédio para entrar em sua casa, fato esse presenciado por Jéssica. Trabalha como motorista de caminhão, mas não possui caminhão próprio. Tem dois filhos maiores de idade. É solteiro e reside com sua mãe há dois anos. Estudou até a oitava série. Usa cocaína desde os dezenove anos. Faz tratamento para dependentes químicos há bastante tempo, atualmente no CAPS. Estima que ainda faltam 7 ou 8 anos de pena a cumprir (gravação audiovisual - pp. 129/130).

J.C.B. disse que conhece o acusado porque ele é filho da vizinha que reside no prédio onde se localiza o escritório de contabilidade. Informou que a contabilidade fica no primeiro andar e o imóvel da vizinha fica um andar acima. Narrou que era fim de semana e a vizinha telefonou dizendo que o acusado tinha arrombado a porta do imóvel. Ela dizia que não sabia o que ele estava fazendo no escritório. Contou que foi ao local e encontrou o estabelecimento revirado, notando a falta de dois telefones celulares. Um deles foi imediatamente apreendido pelo policial e o outro encontrado posteriormente com o réu. Soube que ele acessou o imóvel pelo quintal do apartamento de sua mãe e, então, arrombou a porta da varanda para ingressar no interior do escritório. Informou que o réu revirou caixas e documentos e consumiu bebidas alcoólicas que lá se encontravam. Disse que os aparelhos celulares subtraídos do escritório estavam sobre uma mesa. No momento em que chegou, a Polícia estava no local e os bombeiros já haviam levado o acusado para atendimento, de modo que não teve contato com ele na ocasião. Explicou que foi necessário colocar uma escada do quintal da casa da mãe do réu até o andar do escritório para resgatá-lo. Já conhecia o acusado, pois o viu pelos corredores do edifício em outras ocasiões. Afirmou que, certa vez, ele arrombou um portão do condomínio para ter acesso à casa da mãe dele. Afirmou que os dois celulares foram recuperados e que a empresa não sofreu prejuízos, esclarecendo que a porta arrombada pelo réu foi consertada pelo padraço do acusado. Relatou que os fatos ocorreram em um domingo e as portas estavam trancadas quando deixou o local, na sexta-feira. Reconheceu o réu na audiência virtual. Contou que soube que os bombeiros foram acionados porque o sobrinho da vizinha, que é bombeiro, a visitava no momento (gravação audiovisual - pp. 129/130).

Marco Antonio Quirino, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento e foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência em que o Corpo de Bombeiros atuava para resgatar uma pessoa que havia caído em um prédio. O oficial bombeiro informou que o indivíduo residia no prédio e estava andando sobre o telhado, caindo na área interna de um escritório. Acionaram a Polícia porque, durante a tentativa de resgate da pessoa caída, perceberam que a porta do estabelecimento estava arrombada e os móveis revirados. Afirmou que o acusado se encontrava sob efeito de drogas e encontraram em seu poder um telefone celular modelo iPhone. Disse que o réu informou que o telefone era dele, mas a mãe confirmou que aquele não era o telefone celular do acusado. Conduziram-no à delegacia de polícia. Disse que um representante da empresa foi até o escritório antes de se dirigir ao distrito policial e informou que no local dos fatos notou a falta de dois telefones celulares, um da cor branca e um roxo, ambos da marca Apple, modelo iPhone. Não haviam revistado o acusado até aquele momento. Então, na busca pessoal, encontrou o outro celular dado como faltante, de cor roxa, e que estava no interior das vestimentas inferiores. Afirmou que o responsável pela empresa faria o levantamento para constatar se algo mais havia sido subtraído. Não se recorda do horário dos fatos. Disse que não vistoriou a porta arrombada, pois o único acesso era aquele no qual o réu caiu, esclarecendo que o representante da vítima ainda não havia chegado

(gravação audiovisual – pp. 129/130).

Luciana Kuyavsky, policial militar, relatou que foram acionados para dar apoio a uma ocorrência do Corpo de Bombeiros. Disse que o réu havia caído de uma altura de cerca de dez metros. Teve conhecimento de que o acusado era morador do prédio e estava no telhado quando caiu na área de um escritório de contabilidade. Ele arrombou a porta do estabelecimento e subtraiu dois celulares do local. Contou que os bombeiros o resgataram e o levaram para atendimento médico. Após ser liberado pelos bombeiros, foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso. Declarou que uma funcionária da empresa de contabilidade compareceu à delegacia e reconheceu os celulares como sendo de propriedade da empresa. Ato contínuo, foi feito o auto de apreensão e entrega dos aparelhos celulares. Esclareceu que foi a responsável por dirigir a viatura policial e seu parceiro foi quem entrou no local para acompanhar a equipe dos bombeiros. Como não entrou no imóvel, não sabe informar se havia vestígios de queda accidental ou da intenção de arrombamento. Não se recordou da fisionomia do acusado na audiência virtual. Afirmou que um familiar do réu informou que ele era usuário de drogas, mas não se lembra se naquela ocasião ele estava alterado (gravação audiovisual – pp. 129/130).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Vê-se, assim, que o contexto probatório aqui amealhado se revela coerente, harmônico e uníssono, dando ensejo ao desate condenatório.

Sob o crivo do contraditório, a representante da vítima declarou que foi avisada pela mãe do acusado, que reside no mesmo prédio no qual se situa o escritório de contabilidade. Esclareceu que, por ser fim de semana, o escritório estava fechado e a mãe do réu informou que seu filho havia arrombado a porta, sem saber o que o acusado estaria fazendo lá dentro.

Disse, ainda, que foi ao local e o réu já havia sido levado dali, encontrando uma equipe policial que ali permanecia. Ao entrar, encontrou os móveis e documentos revirados, percebendo a falta de dois aparelhos celulares que estavam sobre a mesa. Um dos aparelhos estava apreendido com um dos policiais naquele momento, enquanto o outro foi recuperado mais tarde.

Os policiais militares informaram que foram acionados para dar apoio a uma ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros. Durante o resgate, a equipe dos bombeiros constatou que o acusado havia arrombado a porta do imóvel em que caiu e, por isso, acionou a Polícia Militar.

Consta que a equipe do Corpo de Bombeiros relatou aos policiais que o acusado era morador do edifício e caiu da laje quando estava sobre o telhado.

O policial Marco Antonio disse que em poder do acusado foi encontrado um telefone celular, tendo o réu afirmado que o objeto era seu. No entanto, o acusado foi desmentido por sua mãe, que confirmou não se tratar do aparelho celular do réu. Após a verificação do local pela representante da vítima, foi constatada a falta de dois celulares, motivo pelo qual, realizou-se a revista do acusado na delegacia de polícia, encontrando-se o segundo aparelho dentro das vestimentas íntimas do réu. Assim, certo está que a confissão, ainda que parcial e manifestada na fase judicial, encontra seguro conforto na prova aqui reunida, que indica o desate condenatório.

E, por certo, não se cogita de conduta atípica, como pareceu à Defesa, já que inaplicável à situação ora analisada a inimputabilidade penal por incapacidade absoluta do réu de entender o caráter ilícito dos fatos que praticava.

Ressalte-se que o argumento é descabido, pois na hipótese sub judice claro está o dolo que animou a conduta do réu, que tinha plena consciência do que fazia. Note-se que narrou detalhadamente sua conduta, afirmando que estava drogado e sofria alucinações, que o animaram a ingressar no local.

Evidente que essa narrativa não é desconexa e nem se mostra alheia à situação de fato aqui retratada, situação que confirma que o acusado não era incapaz de entender o que fazia.

Ademais, o interrogatório denota que o réu é realmente orientado, possui bom nível intelectual e não há sinais de que a alegada dependência química tenha alterado seu comportamento, a ponto de não possuir plena capacidade de determinação.

Por outro lado, ainda que se tenha notícia de que pudesse estar drogado no momento da prática da infração penal, nada nos autos indica efetiva incapacidade, ainda que parcial.

E, como se sabe, para a sistemática do Código Penal, a imputabilidade é a regra e a inimputabilidade a exceção, uma vez que o dolo e a imputabilidade são presumidos. É certo que o acusado se diz viciado, mas a dependência de drogas, por si só, não é capaz de ensejar o reconhecimento de inimputabilidade ou mesmo semi-responsabilidade.

Na verdade, necessário reafirmar que o réu tem plena capacidade de discernimento e determinação no tocante ao seu comportamento criminoso.

Assim, há de ser reconhecida sua plena imputabilidade e responsabilidade penal, sem que se entenda caracterizada qualquer causa de redução de pena ou exclusão da culpabilidade, já que o estado de embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade do agente, conforme previsto no artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Sobre o tema, colhe-se da lição de Guilherme de Souza Nucci que "é fortuita a embriaguez decorrente do acaso ou meramente acidental, quando o agente não tinha a menor ideia de que estava ingerindo substância entorpecente (porque foi ludibriado por terceiro, por exemplo) ou quando mistura o álcool com remédios que provocam reações indesejadas, potencializando o efeito da droga, sem estar devidamente alertado para isso [...]. Embriaguez decorrente de força maior é a que se origina de eventos não controláveis pelo agente, tal como a pessoa que, submetida a um trote acadêmico violento, é amarrada e obrigada a ingerir, à força, substância entorpecente. [...] Essa causa dá margem a uma excludente de culpabilidade se, por conta dessa ingestão forçada ou fortuita, o agente acaba praticando um injusto. É preciso, no entanto, que esteja totalmente incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento por conta da embriaguez completa" (Código Penal Comentado, 15ª edição, São Paulo, Editora Forense, pp. 309/310).

No mesmo sentido, Damásio de Jesus leciona que: "Se o sujeito comete uma infração penal sob efeito de embriaguez, voluntária ou culposa, não há exclusão de imputabilidade e, por consequência, não fica excluída a culpabilidade. Ele responde pelo crime" (Direito Penal, 1º volume, p. 449).

E, acolhendo esse entendimento, adequado citar julgados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a saber:

"Cumpre mencionar também que o fato de o acusado estar embriagado no momento das infrações não tem o condão de afastar a sua responsabilidade penal, uma vez que a embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não impede a caracterização do delito, ainda que plena, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior, nos expressos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, circunstâncias essas não demonstradas pelas provas amealhadas aos autos. Desta forma, a ingestão voluntária ou culposa de drogas ou álcool, como in casu, não exclui a imputabilidade penal." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500288-49.2021.8.26.0611, Des. Rel. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 29/07/2022).

"A eventual embriaguez ou drogadição voluntária no momento dos fatos é circunstância que, segundo a teoria da actio libera in causa, não afasta e nem mitiga a imputabilidade, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Em verdade, a única espécie de embriaguez que tem o condão de afetar responsabilidade penal é a completa decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito do fato, ex vi dos §§1º e 2º do aventado dispositivo legal, não verificada na espécie." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500048-30.2020.8.26.0600, Des. Rel. Camargo Aranha Filho, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. em 28/07/2022).

"Apelação Criminal. Roubo circunstanciado em continuidade delitiva. Recursos defensivos e ministerial. Materialidade e autoria demonstradas, sem impugnação pela via. Confissão dos acusados corroborada pelos demais elementos probantes. Embriaguez voluntária do agente que não exclui sua imputabilidade penal.

Inteligência do art. 28, inciso II, do Código Penal. Condenação mantida. (...)"

(TJSP, Apelação Criminal nº 0000995-36.2016.8.26.0589, Des. Rel. Freire Teotônio, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. em 26/07/2022)

De se frisar que a prova revelou que o acusado tem plena capacidade de discernimento e determinação no tocante ao seu comportamento. Também é certo que sabe que crimes contra o patrimônio proporcionam meios de usuários de drogas lícitas ou ilícitas manter e perpetuar o vício.

E, como já se decidiu:

Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Reconhecimento da inimizabilidade em razão da dependência química - Impossibilidade - Não demonstração nos autos de que o apelante tinha o discernimento comprometido tanto no momento da ação, como em qualquer ato do processo - Condenação mantida - Recurso improvido. Pena-base acima do mínimo legal - Maus antecedentes - Inexistência de informação quanto ao trânsito em julgado para a defesa da condenação utilizada - Recurso provido em parte para redimensionar a reprimenda na primeira etapa ao mínimo. Continuidade delitiva - Fração de dois terços mantida - Proporcionalidade diante do número de bens jurídicos vulnerados - Recurso improvido. Isenção de custas - Pleito que deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções penais competente - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500703-

37.2019.8.26.0438; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 08/03/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. [...] ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. AFASTAMENTO. O uso de drogas - lícitas ou ilícitas - por si, salvo excludentes de embriaguez ou drogadição por acidente ou erro, não eximem a culpabilidade. No contexto global do vício, nos tempos de hoje, em que alguns inclusive defendem a liberação de algumas drogas ilegais que causam dependência, é incabível a discussão isolada da situação e intolerável o possível efeito cascata que certamente há de vir defendido pensadores de plantão, de molde a se verificar teses erigindo a conduta dos dependentes simplesmente à inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Tratar-se-ia de alimentar mais e mais a ideia que nefastamente vem sendo plantada na sociedade moderna, lamentavelmente, de que usar droga é normal e consequentemente cometer crimes por conta disso é exculpável. Alegação rechaçada. [...] (Apelação Crime Nº 70052559036, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel.: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 21/11/2013).

De igual modo, não merece crédito a versão apresentada pelo réu no sentido de não pretender subtrair objetos do escritório de contabilidade.

Sabe-se que o réu não está obrigado a dizer a verdade: ao contrário, bem pode pretender alterar a verdade dos fatos, procurando afastar sua responsabilidade penal, justamente para não se prejudicar.

Nestes termos, inaceitável a versão que o réu ofertou, pois quis fazer crer que, em razão de ingestão de drogas e bebidas alcoólicas, transitava pelo telhado do edifício onde reside e, acidentalmente, caiu no andar do imóvel da empresa vítima. Arrombou a porta da varanda do escritório pois ouviu vozes e teve alucinações, assim agindo para expulsar as pessoas que ali estivessem.

Por este motivo, revirou o local a procura de tais pessoas e apropriou-se de dois aparelhos celulares supondo que fossem bens dos invasores, com a intenção de coibi-los a dali saírem.

Evidente que não há como admitir a fantasiosa versão, uma vez que a prova revela que a intenção do acusado era se apoderar de bens valiosos, razão pela qual invadiu o local.

Destaque-se que, como se apurou, ao ser indagado pela equipe policial sobre um dos celulares encontrados em seu poder, consta que o réu declarou que referido aparelho era seu, o que foi prontamente desmentido pela mãe do acusado.

Outrossim, e diante da informação da representante da empresa, relativamente à falta de outro aparelho celular, foi o réu revistado, encontrando-se com ele o segundo aparelho subtraído, cuidadosamente escondido em suas vestes íntimas, e isso quando o acusado já estava na repartição policial, horas após ser retirado do local do crime.

Frise-se, ainda, que apesar de ter o réu declarado que caiu do telhado, afirmando

que se tratava de local situado a dez metros de altura, bem se vê que não suportou ferimento algum (pp. 80/81 e 82/83), o que efetivamente demonstra que o réu lá ingressou por vontade própria, sem que qualquer acidente tenha sido verificado. Inequivocamente comprovado que se tratou de subtração consumada, uma vez que o acusado teve posse mansa e pacífica das res, ainda que por curto período de tempo. Não se cogita de desclassificação para reconhecimento de crime tentado, como pretendeu a Defesa, e isso porque se considera consumado o delito quando o agente desloca ou remove a coisa, invertendo-lhe a posse, ainda que por breve período, sendo desnecessário, inclusive, que a posse seja tranquila, pacífica e desvigiada, segundo a teoria "amotio".

Neste sentido, é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Tema 934 - REsp nº 1524450).

Além disso, indiscutível é a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo, como descrita na denúncia.

Em juízo, a representante da vítima esclareceu que foi a responsável por trancar o escritório na sexta-feira e que as portas estavam em perfeito estado.

Ademais, de acordo com o laudo de exame do local, foi possível identificar o arrombamento da porta, conforme fotografias 4 e 5 (pp. 120/121), além de apurar-se que "por ocasião dos exames, ao se acessar a parte interna do imóvel foi possível constatar desordem generalizada, com diversos objetos espalhados pelo chão, com o conteúdo dos armários revirados" (laudo de pp. 116/123).

Desta forma, os relatos da funcionária do escritório e dos policiais militares, somados à confissão do acusado e à prova pericial, confirmam que a subtração dos bens armazenados no interior do imóvel foi praticada mediante rompimento de obstáculo, sendo forçoso reconhecer que demonstrada está a qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal.

Por outro lado, tem razão a Defesa quanto ao afastamento da ocorrência da causa de aumento de pena do repouso noturno, não sendo possível reconhecer sua caracterização.

Em recente julgado, proferido em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal é aplicável tão somente ao caput: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)." (REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022 (Tema 1087)).

Assim, parece que o afastamento da causa especial de aumento de pena é desfecho adequado à situação aqui apurada, uma vez que os fatos narrados na denúncia imputam ao réu a prática do furto qualificado por rompimento de obstáculo.

Com efeito, ao que narra a denúncia, o crime ocorreu por volta de 21h30min, ou seja, durante a noite, mas como exposto, e segundo o entendimento da Corte Superior, o parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal não mais incide na forma qualificada do crime de furto.

Desta forma, é caso de afastar a incidência desta causa de aumento de pena do repouso noturno.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, portanto, a ação penal.

Passo à individualização da pena.

Destaque-se que, não obstante afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno, por não incidir no furto qualificado, a situação de fato não pode ser desconsiderada pelo juízo.

Não há dúvida de que o furto cometido durante a noite – período em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminoso em razão da diminuição da vigilância exercida sobre a res – é circunstância determinante no modus operandi dos criminosos.

Assim sendo, essa especificidade será considerada nas circunstâncias judiciais.

O acusado é reincidente, pois possui cinco condenações definitivas por crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro (autos n.º 0006735-35.2001.8.26.0157 - certidão p. 153), associação criminosa (autos n.º 0030696-59.2002.8.26.0451 - certidões pp. 154 e 158), roubo majorado (autos n.º 0067140-57.2003.8.26.0451 - certidões pp. 154/155 e 157/158) e receptação (autos n.º 861/2001, execução n.º 700233-95.2004.8.26.0032 - certidão p. 158 e FA p. 138).

Além disso, se vê processado por furto qualificado (autos n.º 1503709-98.2021.8.26.0536 - certidão p. 155), destacando-se que tal apontamento não será aqui considerado, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Na hipótese sub judice, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão da circunstância desfavorável do crime, pois o furto foi praticado durante o repouso noturno, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Comprovada a reincidência representada por condenações definitivas pela prática de cinco crimes, quatro deles contra o patrimônio (extorsão, extorsão mediante sequestro, roubo majorado e receptação), o que não poderia ser desprezado, agravo a pena em 1/2 (metade), fixando-a em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 16 (dezesesseis) dias-multa.

De outro lado, o réu admitiu, em parte, a prática da conduta criminosa.

Consoante estabelece o artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

No entanto, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência.

A respeito decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"... REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal." (RHC 141519, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, processo eletrônico dje-223 divulg 08-09-2020 public 09-09-2020).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas.

Afora isso, verifica-se a existência de cinco condenações anteriores em desfavor do acusado, todas aptas a configurar a reincidência, o que desautoriza a concessão da pleiteada compensação.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"... A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, se tratando de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade..." (HC 531.187/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)..." (AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

"...Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência..." (AgRg no HC n. 626.637/SC, relator Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021)

Assim, presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstâncias que a modifiquem.

Apesar do quantum da pena aplicada, ante a reconhecida reincidência representada por cinco condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, e evidenciadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime), iniciará o réu o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, este não só pelo quantum da pena imposta, mas especialmente em razão da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como porque a substituição não seria recomendável e nem suficiente para reprovação da conduta delituosa.

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar KLEBER SANTOS SILVA, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual n.º 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O acusado viu convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. É certo que o fato aqui apurado desassossega a sociedade, compromete a paz social e desequilibra a ordem pública.

Assim, a prisão por sentença condenatória recorrível se revela necessária, seja para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como para resguardo da ordem e paz públicas.

Lembre-se que o réu é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, possuindo condenações definitivas por crimes de extorsão, extorsão mediante sequestro, roubo majorado e receptação. Além de estar sendo processado pela prática de furto qualificado (p. 155).

Por final, necessário registrar que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para acautelar o procedimento, agora julgado nesta Instância, sendo forçoso reconhecer que, em liberdade, o acusado poderá por em risco a aplicação da lei penal, pois condenado a cumprir pena em gravoso regime, destacando-se que quando cometeu o presente delito estava cumprindo pena em regime aberto.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de arbitrar a reparação dos danos, pois, diferentemente do pleito formulado pelo Ministério Público a p. 58, consta que a empresa não suportou prejuízos financeiros.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 2 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA